OBJECTIF BARREAU

LES ESSENTIELS DU DROIT

-

DROIT SOCIAL

THÈME I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL

Le droit du travail regroupe les règles légales, réglementaires et jurisprudentielles qui ont pour destinataires les salariés, c'est-à-dire les travailleurs titulaires d'un contrat de travail, et les employeurs. Ses dispositions figurent, bien sûr, dans le Code du travail. Néanmoins, le droit du travail se caractérise surtout par la diversité de ses sources. De plus, le droit social est une matière « *vivante* » qui évolue sans cesse.

LA HIERARCHIE DES SOURCES DU DROIT DU TRAVAIL

1. Bloc de constitutionnalité

La Constitution de 1958 comporte peu de dispositions directement consacrées au droit du travail. Son article 34 confie à la loi la détermination des principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale. Le Préambule de 1946, auquel renvoie celui de 1958, consacre notamment le droit d'obtenir un emploi, la liberté syndicale, le droit de grève et la participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail. . En revanche le Préambule de la constitution de 1946, intégré au bloc de constitutionnalité, comprend de nombreuses dispositions relatives au droit du travail. Il consacre, en particulier, un certain nombre de droits économiques et sociaux « particulièrement nécessaires à notre temps » relatif au travail. Il proclame en particulier le droit au travail, la liberté syndicale, le droit de grève…

2. Traités et conventions internationales, droit communautaire

Parmi les normes de niveau international, le pacte international relatif aux droits civils et politiques interdit le travail forcé (article 8) et proclame le principe de non-discrimination (article 26). Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels proclame un droit à la formation (article 6.2), le droit à des conditions de travail justes (article 7) ou encore le droit syndical et le droit de grève (article 8)

Au niveau international, il existe l'Organisation Internationale du Travail (OIT) spécifiquement dédiée aux problématiques liées au travail. Cette organisation a été créée en 1919 et est désormais rattachée à l'ONU. L'OIT adopte des conventions internationales, elle reçoit et traite les plaintes dénonçant le non-respect des conventions adoptées.

L'activité majeure de l'OIT est une activité normative, elle a adopté plus de 190 conventions. Les États membres, dont la France fait partie, peuvent ratifier ces conventions pour qu'elles leur soient applicables. Les conventions de l'Organisation internationale du travail obligent les États qui les ont ratifiées. Leur application fait l'objet de mécanismes internationaux de contrôle, notamment par l'examen de rapports, les réclamations et les plaintes. L'OIT ne dispose pas d'un système général de sanctions pécuniaires comparable à celui d'une juridiction nationale ; ses mécanismes de contrôle peuvent toutefois donner lieu à des constats, recommandations et procédures institutionnelles dont la portée ne saurait être réduite à des condamnations "symboliques". . Cependant les condamnations prononcées sont uniquement symboliques.

Le droit européen est une source majeure du droit du travail français. Il faut distinguer le droit de l'Union européenne — notamment les traités, la Charte des droits fondamentaux, les règlements et les directives — et le droit du Conseil de l'Europe, en particulier la Convention européenne des droits de l'homme et la Charte sociale européenne. Ces normes influencent directement de nombreux domaines : non-discrimination, temps de travail, santé et sécurité, information et consultation des travailleurs ou protection des droits fondamentaux. .

3. Lois et règlements, code du travail

Comme il l'a été précédemment précisé, l'article 34 de la Constitution donne compétence au législateur pour fixer les normes relatives au droit du travail. L'article L. 1 du Code du travail prévoit que tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement portant sur les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi ou la formation professionnelle, lorsqu'il relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle, fait

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives à ce niveau, en vue de l'ouverture éventuelle d'une négociation. En cas d'urgence, le Gouvernement peut écarter cette procédure, mais il doit motiver sa décision et la communiquer aux organisations concernées

Le Code du travail regroupe une partie législative et une partie réglementaire, sans épuiser l'ensemble des règles applicables aux relations de travail, qui figurent aussi dans d'autres codes et dans des textes non codifiés. .

Afin de renforcer la place de la négociation collective parmi les sources du droit du travail, la loi Travail du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, organise la réécriture d'une partie du Code du travail selon le triptyque suivant :

- Ordre public (auquel il ne peut être dérogé par accord collectif) ;
- Champ de la négociation collective : les matières dans lesquelles un accord collectif peut déterminer les règles applicables, dans les limites fixées par l'ordre public ;
- Dispositions supplétives : les règles légales applicables à défaut d'accord collectif

Attention à l'articulation entre accord de branche et accord d'entreprise. Depuis les ordonnances de 2017, les articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail organisent trois ensembles de matières : 1/ celles dans lesquelles l'accord de branche prévaut, sauf garanties au moins équivalentes prévues par l'accord d'entreprise ; 2/ celles dans lesquelles la branche peut verrouiller la matière dans les conditions légales ; 3/ les autres matières, dans lesquelles l'accord d'entreprise prévaut, qu'il soit antérieur ou postérieur à l'accord de branche. Il faut donc distinguer l'articulation entre la loi et l'accord collectif du rapport entre accord de branche et accord d'entreprise.

La jurisprudence est une source importante en droit du travail, qu'il s'agisse, pour l'essentiel, de la jurisprudence de la Cour de cassation, mais aussi, de manière plus marginale de celle du Conseil d'État et de juridictions européennes (CJUE ; CEDH).

4. Convention collectives et accords collectifs de travail

Les conventions collectives sont des actes particuliers en droit français, elles existent uniquement en matière de droit du travail puisque celles-ci sont conclues entre les représentants des salariés et les représentants des employeurs.

La convention ou l'accord collectif de travail est un « *acte normatif négocié entre un employeur ou un groupement d'employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés, en vue de fixer en commun les conditions d'emploi et de travail, ainsi que les garanties sociales* ». Elles peuvent être conclues à différents niveaux : accord national interprofessionnel, accord de branche, de groupe, d'unité économique et sociale, accord interentreprises, accord d'entreprise, accord d'établissement.

Elles sont dotées d'un réel pouvoir normatif puisqu'elles vont s'appliquer à tous les salariés des employeurs qui les ont signées soit directement, soit indirectement par le biais de l'organisation patronale dont ils sont membres. Une convention ou un accord de branche s'applique aux employeurs liés par le texte, notamment en raison de leur adhésion à une organisation patronale signataire, et à leurs salariés compris dans son champ d'application. Lorsqu'il fait l'objet d'un arrêté d'extension, ses stipulations rendues obligatoires s'appliquent également aux employeurs non liés initialement par l'accord, dès lors qu'ils entrent dans son champ professionnel et territorial, ainsi qu'à leurs salariés (Article L. 2261-15 du Code du travail).. .

Les réformes récentes du droit du travail (loi Travail du 8 août 2016 et ordonnances « Macron » du 22 septembre et 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification le 29 mars 2018) ont accentué la place des conventions et

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

accords collectifs de travail à tel point que la loi devient parfois supplétive, s'effaçant lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail a été conclu. Le législateur n'a eu de cesse d'encourager la négociation d'accords collectifs (obligations de négocier, procédure de sauvetage lors de la conclusion d'accords collectifs, négociation d'accord possible dans les petites entreprises).

Le régime des conventions et accords collectifs de travail a été profondément remanié par la loi « Travail » du 8 août 2016, puis par les ordonnances du 22 septembre 2017.

5. Usages et engagements unilatéraux de l'employeur

L'usage d'entreprise est caractérisé par une pratique générale, constante et fixe : 1/ générale : l'avantage bénéficie à l'ensemble des salariés ou à une catégorie objectivement déterminée d'entre eux ; 2/ constante : il est attribué de manière répétée ; 3/ fixe : ses modalités d'attribution reposent sur des critères suffisamment déterminés

C'est donc une pratique répétée depuis un certain temps, qui octroie des droits aux salariés. L'idée est que la répétition d'une pratique démontre l'existence d'une règle, non explicitement formulée, mais qui devient obligatoire. Les usages peuvent être des usages professionnels ou locaux, ou encore, des usages d'entreprise.
La jurisprudence accorde à l'usage un caractère obligatoire qui s'impose à l'employeur. Il s'agit d'une source de droit autonome qui ne s'incorpore pas au contrat de travail. L'usage s'impose à l'employeur à moins qu'il ne dénonce l'usage. Cette dénonciation suppose une information des représentants du personnel, une information personnelle de chacun des salariés concernés par l'avantage et le respect d'un préavis raisonnable pour permettre des négociations.

L'engagement unilatéral de l'employeur est un acte par lequel un employeur s'engage à accorder un avantage déterminé à un ou plusieurs salariés de l'entreprise.Il résulte d'une manifestation de volonté claire de l'employeur d'accorder un avantage aux salariés concernés, lesquels peuvent être l'ensemble du personnel ou une catégorie déterminée. . À la différence de l'usage qui suppose une pratique constante, fixe et générale, la seule expression de volonté de l'employeur suffit à caractériser l'engagement unilatéral. La Cour de cassation lui reconnaît la même portée que l'usage. Sa dénonciation obéit aux mêmes règles que celles applicables à la dénonciation d'un usage.

6. Normes professionnelles (règlement intérieur développement ci-dessous)

7. Contrat de travail (développement ci-dessous)

L'ARTICULATION DES SOURCES DU DROIT DU TRAVAIL

En raison de la multitude des sources en droit du travail, il n'est pas rare que ces normes entrent en conflit. Celui-ci se résout de différentes manières :

- Le respect des normes impératives. Une norme inférieure ne peut écarter une règle supérieure à laquelle il est interdit de déroger. En droit du travail, il faut toutefois distinguer les règles d'ordre public, les règles auxquelles une dérogation plus favorable est admise et celles pour lesquelles la loi autorise expressément une dérogation par accord collectif, y compris moins favorable. L'article L. 2251-1 du Code du travail permet à la convention ou à l'accord collectif de comporter des dispositions plus

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

favorables aux salariés que les lois et règlements en vigueur, mais interdit de déroger aux dispositions présentant un caractère d'ordre public

- **Il est également possible d'utiliser le principe de faveur, c'est-à-dire appliquer la règle la plus favorable au salarié** :il est alors possible d'écarter une règle supérieure au profit d'une règle inférieure plus favorable au salarié. Le principe de faveur ne constitue pas une règle universelle de résolution de tous les conflits de normes : son application dépend des textes régissant leur articulation. . Ainsi, l'article L. 2251-1 du Code du travail traduit cette possibilité de dérogation « in melius » en disposant que : « *La convention et l'accord collectif du travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur* ». De même, l'article L. 2254-1 du Code du travail fait prévaloir les stipulations plus favorables du contrat de travail sur celles de la convention collective.
- **Ou encore, d'appliquer la règle de spécialité, c'est-à-dire d'appliquer la règle dont le champ d'application est le plus étroit.** Depuis 1982, cette règle de spécialité est appliquée dans les rapports entre la loi et les accords collectifs. En effet, la loi prévoit les cas dans lesquels des accords collectifs peuvent prévoir des dispositions différentes de celles de la loi, sans être nécessairement plus favorables (« accords dérogatoires »). Mais plus largement, le domaine du principe de faveur s'est rétréci au fil des réformes successives. Et on arrive à l'essor d'un :

- La primauté de l'accord d'entreprise dans les matières prévues par la loi. Les articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail organisent l'articulation entre accord de branche et accord d'entreprise. Dans les matières relevant de l'article L. 2253-3, l'accord d'entreprise prévaut, même s'il est moins favorable que l'accord de branche. Cette primauté connaît toutefois les exceptions prévues aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 .

- **Principe de supplétivité :** La loi prévoit qu'un accord collectif peut déroger à la loi. Ce n'est qu'à défaut d'accord collectif que la loi s'applique. Cette méthode a été retenue par la loi du 8 août 2016 dans le domaine du temps de travail. Elle a été étendue par les ordonnances du 22 septembre 2017, par exemple s'agissant des attributions du Comité social et économique (nous avons évoqué plus haut l'architecture tripartite de certaines règles du Code du travail).

- **Les mécanismes de substitution** : Depuis la loi du 8 août 2016, l'accord de groupe peut prévoir des clauses permettant à cet accord de se substituer aux clauses ayant le même objet de l'accord d'entreprise ou d'établissement ayant le même objet. De plus, les accords de « performance collective » (ordonnance du 22 septembre 2017) permettent d'organiser des modifications du contrat de travail des salariés. L'accord de performance collective peut prévoir des stipulations qui se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail. Le salarié peut refuser cette modification. L'employeur peut alors engager une procédure de licenciement reposant sur un motif spécifique, que la loi qualifie de cause réelle et sérieuse, sous réserve du respect des conditions et de la procédure prévues à l'article L. 2254-2 du Code du travail. Le refus du salarié n'entraîne donc pas automatiquement son licenciement. .

LES INSTITUTIONS DU DROIT DU TRAVAIL : Le droit du travail se caractérise par l'existence de deux institutions particulières :

- **L'inspection du travail** est une autorité administrative en charge de contrôler l'application du droit du travail par les entreprises. Depuis le 1er avril 2021, la DREETS (Direction régionale de l'économie, de

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

l'emploi, du travail et des solidarités) remplace la DIRECCTE. L'article L8112-1 du Code du travail dispose que les inspecteurs du travail ont pour fonction de veiller à l'application du droit du travail dans son ensemble, y compris des conventions collectives. L'article L8112-2 du Code du travail précise que ceux-ci doivent notamment veiller au respect des dispositions relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs. Ils disposent d'une garantie d'indépendance dans l'exercice de leurs missions au sens des conventions internationales concernant l'inspection du travail. Les inspecteurs du travail peuvent être saisis de plaintes et de réclamations de la part des salariés. L'inspection du travail exerce également certaines compétences décisionnelles, notamment en matière d'autorisation de licenciement des salariés protégés et, dans les cas prévus par les textes, de dérogations à certaines règles du droit du travail. Il faut toutefois distinguer ces compétences de celles de l'autorité administrative compétente : l'homologation des ruptures conventionnelles individuelles ordinaires et la validation ou l'homologation des plans de sauvegarde de l'emploi ne sont pas, en tant que telles, des décisions prises par l'inspecteur du travail. La rupture conventionnelle d'un salarié protégé obéit, elle, à un régime particulier d'autorisation par l'inspecteur du travail

- . Pour effectuer leurs fonctions, les inspecteurs du travail peuvent procéder à des investigations : ils peuvent entrer dans toutes les entreprises (article L8113-1 du Code du travail) et peuvent accéder à tous les registres obligatoires (article L8113-4 du Code du travail).

- **Le conseil de prud'hommes est la juridiction de l'ordre judiciaire compétente, en principe, pour les litiges individuels nés à l'occasion d'un contrat de travail de droit privé, entre employeurs et salariés. (Article L. 1411-1 du Code du travail).** . L'article L1411-1 du Code du travail dispose que le Conseil de prud'hommes est compétent pour juger de tous « *les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail* ». Tous les litiges relatifs au contrat de travail sont de sa compétence (formation, exécution, conditions de travail, rupture du contrat de travail, harcèlement, discrimination, etc.). Il est compétent uniquement pour les litiges à caractère individuel. La procédure devant le conseil de prud'hommes présente certaines particularités. Les parties doivent tenter préalablement de concilier devant le bureau de conciliation et d'orientation ; à défaut, l'affaire est renvoyée devant le bureau de jugement.

Les litiges collectifs relevant de l'ordre judiciaire sont, en principe, portés devant le tribunal judiciaire, notamment lorsqu'ils concernent la validité ou l'application collective d'un accord. Certains litiges du travail relèvent toutefois du juge administratif, en particulier lorsqu'ils portent sur des décisions administratives prises dans le cadre du droit du travail .

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

PARTIE I : LA RECONNAISSANCE DE LA RELATION DE TRAVAIL

LA QUALIFICATION DE CONTRAT DE TRAVAIL conditionne l'application des textes du droit du travail ; s'agissant des relations individuelles, la reconnaissance d'un contrat de travail appelle aussi l'action du Conseil de prud'hommes. Le Code civil assimilait ce contrat à un contrat de louages de services ; le Code du travail ne livre aucune définition du contrat de travail et se contente de renvoyer au droit commun des contrats. Si bien qu'il convient de constater que le contrat de travail n'a pas de définition légale mais une définition doctrinale et jurisprudentielle. **La définition généralement admise est la suivante : Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique, le salarié, s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne physique ou morale – l'employeur – sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération.**

Enfin, il est nécessaire de rappeler que la qualification choisie par les parties est sans importance sur la nature du lien juridique : ainsi la dénomination d'un contrat d'exercice libéral n'interdit pas au juge de rechercher si, en réalité, les parties sont liées par un contrat de travail (principes d'indisponibilité et de réalité).

Le contrat de travail se définit donc par 3 critères cumulatifs :

1) ***L'exécution d'une prestation de travail*** . La prestation de travail peut être manuelle, intellectuelle, artistique ou sportive. Une activité accomplie dans un cadre de formation, d'insertion, associatif ou religieux ne doit pas être exclue par principe de la qualification de travail salarié : il faut examiner la finalité de l'activité, le cadre juridique applicable et les conditions concrètes de son exécution. La Cour de cassation a notamment jugé que l'engagement religieux n'exclut pas, à lui seul, la recherche d'un contrat de travail : l'exclusion reconnue pour certaines activités religieuses répond à des conditions précises. (Cass. soc. 20 janvier 2010 n° 08-42.207 .
2) ***Le versement d'une rémunération*** : quelles qu'en soient la forme et l'importance, en nature ou en argent.
3) ***Un lien de subordination juridique*** défini par l'arrêt fondateur « Société Générale » du 13 novembre 1996 qui énonce que « *le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné* » Le lien de subordination se caractérise par le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. Le juge apprécie concrètement l'existence de ces pouvoirs au moyen d'un faisceau d'indices. Le travail au sein d'un service organisé peut notamment constituer un indice de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. En effet, c'est bien l'existence du pouvoir de sanction qui compte (Cass. soc. 13 novembre 1996 n° 94-13.187).

Afin de sécuriser les relations contractuelles, **le législateur a institué une présomption de non-salariat** : ainsi, par exemple, la personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés est présumée ne pas être salarié. La présomption est simple : l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes précédemment citées fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci (C. trav., art. L. 8221-6, II). A l'inverse, certaines activités rendent délicate la démonstration d'un lien de subordination juridique ; c'est la raison pour laquelle le législateur a parfois recours à **une présomption de salariat**. Le législateur prévoit, pour certaines professions, des présomptions ou qualifications légales de contrat de travail, notamment pour les journalistes professionnels (article L. 7112-1), les artistes du spectacle (article L. 7121-3) et les mannequins (article L. 7123-3). Les VRP relèvent, quant à eux, d'un régime légal particulier défini notamment à l'article L. 7311-3 du Code du travail.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

Les travailleurs de plateformes numériques exercent fréquemment sous un statut indépendant, mais ce statut ne fait pas obstacle à la requalification en contrat de travail si les conditions réelles d'exercice de leur activité révèlent un lien de subordination juridique.

Dans l'arrêt Uber du 4 mars 2020, la Cour de cassation a approuvé la requalification de la relation d'un chauffeur en contrat de travail, au regard d'un ensemble d'indices : organisation de la prestation par la plateforme, absence de maîtrise de certains tarifs et conditions d'exécution, contraintes relatives aux courses et possibilité de déconnexion. (Cass. soc. 4 mars 2020 n° 19-13.316) La jurisprudence doit cependant être appréciée au regard des faits de chaque dossier. Dans un arrêt du 5 mars 2025, la Cour de cassation a également censuré une décision ayant écarté le salariat alors que les constatations des juges révélaient des pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction de la plateforme à l'égard du chauffeur. (Cass. soc. 5 mars 2025 n° 23-18.431)

LA CONCLUSION DU CONTRAT DE TRAVAIL suppose le plus souvent une phase de recrutement, encadrée par la loi et peut parfois nécessiter la conclusion d'une promesse d'embauche. La procédure de recrutement est soumise à plusieurs exigences visant à éviter toutes formes de dérives, notamment les discriminations à l'embauche. L'employeur se trouve alors soumis à :

- Une obligation d'information et de confidentialité : le candidat doit être expressément informé, avant leur mise en œuvre, des méthodes et techniques d'aide au recrutement utilisées à son égard ; les résultats obtenus sont confidentiels (article L. 1221-8 du Code du travail). Aucune information personnelle ne peut être collectée au moyen d'un dispositif qui n'a pas été préalablement porté à sa connaissance (article L. 1221-9)**.**
- **Une obligation de pertinence des méthodes et techniques d'évaluation** (article L1221-8, al 3 du Code du travail) : ceci empêche les techniques telles que la sorcellerie ou la numérologie.
- **Une obligation de finalité** (article 1221-6 du Code du travail) : les informations demandées doivent être en rapport direct avec l'emploi sollicité. Il doit exister un lien direct et nécessaire avec l'emploi.
- **Une obligation de non-discrimination** (article L1132-1 du Code du travail) : il est interdit d'écarter une personne d'une procédure de recrutement pour un motif illicite (origine, sexe, orientation sexuelle, âge, opinions politiques, activités syndicales, état de santé, handicap…) Il convient de comprendre la notion de discrimination. Cette notion n'est pas personnelle, ni subjective mais objective et légale. La discrimination est donc une inégalité de traitement reposant sur un des critères énoncés dans le code.

En matière de discrimination, l'article L. 1134-1 du Code du travail prévoit un aménagement de la charge de la preuve : le candidat à un emploi ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; il appartient alors à la partie défenderesse de démontrer que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction, au besoin après avoir ordonné des mesures d'instruction. La procédure mobilise trois types d'acteurs :

- Le salarié : lorsque survient un litige en raison d'une discrimination, le candidat à un emploi présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Le salarié qui relate des faits de discrimination bénéficie d'une protection contre les sanctions et le licenciement fondés sur cette dénonciation. Cette protection ne couvre pas la mauvaise foi, laquelle suppose que le salarié ait eu connaissance de la fausseté des faits dénoncés : le seul fait que la discrimination ne soit finalement pas établie ne suffit pas. Cass. soc., 13 janvier 2021, n° 19-21.138
- L'employeur : au vu des éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

- Le juge : il forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Offre ou promesse d'embauche ? Profitant de la réforme du droit des contrats, la Cour de cassation revient sur les critères de distinction : l'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur. En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis (Soc. 21 sept. 2017, no 16-20.103 et 16-20.104).

Quant au fond, le contrat de travail doit respecter les conditions de validité de droit commun prévues à l'article 1128 du Code civil : le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. .
Le contentieux en ce domaine est relativement faible : l'erreur de l'employeur est parfois qualifiée d'erreur inexcusable ; le dol (mensonge) est surtout traité sur le terrain de l'exécution (faute du salarié) du contrat de travail. Les conséquences éventuelles de l'annulation présentent aussi des particularités : l'effet rétroactif de l'annulation est écarté (s'agissant d'un contrat à exécution successive).

Quant à la forme, le contrat verbal est en principe valable. Cependant, cette absence de formalisme est applicable uniquement en cas de contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Dès lors qu'il s'agit d'un contrat spécial (CDD ou contrat de travail intérimaire) ou d'un contrat à temps partiel (CDD ou CDI), un contrat écrit est exigé et certaines formes sont requises. L'absence d'écrit n'a pas les mêmes conséquences selon le contrat concerné. Le CDD doit être établi par écrit : à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée (article L. 1242-12 du Code du travail). Le contrat de travail à temps partiel doit également être écrit (article L. 3123-6). À défaut d'écrit, le salarié bénéficie d'une présomption simple de travail à temps complet : l'employeur peut la renverser en apportant les preuves exigées par la jurisprudence. .

LE CONTENU DU CONTRAT DE TRAVAIL : L'article L1221-20 du Code du travail dispose que : *« **la période d'essai** permet à l'employeur et au salarié d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent* ». Il s'agit d'une période au cours de laquelle le contrat de travail peut être rompu unilatéralement par chacune des parties sans formalité. La période d'essai doit débuter au commencement de la relation de travail entre l'employeur et le salarié, les parties ne peuvent en différer l'application.

Ne pas confondre période d'essai et période probatoire : cette distinction a été clairement rappelée par le juge dans un arrêt du 25 avril 2001 : une période probatoire en vue d'une promotion professionnelle, en cours d'exécution du contrat, ne constitue pas une période d'essai. À partir de cet arrêt, on peut relever deux différences :

- sur l'existence de la période probatoire : celle-ci est inscrite en cours d'exécution contrat et non au début du contrat ;
- sur le régime de la période probatoire : celle-ci, lorsqu'elle n'est pas concluante, ne débouche pas sur une rupture du contrat, mais oblige le salarié à retrouver son poste antérieur.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

Conditions : La période d'essai ne se présume pas, elle doit être expressément prévue dans le contrat de travail ou dans la lettre d'engagement (article 1221-23 du Code du travail).

Pour le CDI, les durées maximales initiales de la période d'essai sont fixées par l'article L. 1221-19 du Code du travail : deux mois pour les ouvriers et employés, trois mois pour les agents de maîtrise et techniciens et quatre mois pour les cadres. Des durées plus courtes peuvent notamment être prévues dans les conditions de l'article L. 1221-22. Les durées applicables au CDD relèvent d'un régime distinct. .

Dès lors que le salarié est absent durant la période d'essai, celle-ci est prolongée du nombre de jours d'absence. Ainsi, la période d'essai sera prolongée en cas de prise de congés payés, de congés sans solde, d'arrêts maladie ou encore d'accident du travail.

La période d'essai peut être renouvelée une seule fois, sous réserve que plusieurs conditions cumulatives soient réunies : Si un accord de branche étendu le prévoit et si le contrat de travail le prévoit expressément, il faut un accord exprès et sans réserve du salarié ; le renouvellement doit être proposé avant la fin de la période d'essai initiale ; et il ne doit pas être abusif, c'est-à-dire qu'il doit être justifié par la nécessité pour l'employeur de tester à nouveau les aptitudes du salarié.

La période d'essai du CDI peut être renouvelée une seule fois si les conditions légales et conventionnelles sont réunies. Sa durée totale, renouvellement compris, ne peut pas dépasser quatre mois pour les ouvriers et employés, six mois pour les agents de maîtrise et techniciens et huit mois pour les cadres (article L. 1221-21 du Code du travail).

Rupture : Si la rupture de la période d'essai est libre, le Code du travail prévoit tout de même un délai de prévenance imposé aux parties (article 1221-25 du Code du travail). Si l'employeur prend l'initiative de la rupture de la période d'essai, il doit informer le salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à : 24 h en deçà de 8 jours de présence ; 48h entre 8 jours et 1 mois de présence ; 2 semaines après un mois de présence ; 1 mois après 3 mois de présence.

Lorsque le salarié rompt la période d'essai, il respecte un délai de prévenance de 48 heures, ramené à 24 heures si sa durée de présence dans l'entreprise est inférieure à huit jours (article L. 1221-26 du Code du travail).

Il faut distinguer deux situations :

1. La rupture est notifiée avant l'expiration de la période d'essai mais le délai de prévenance n'est pas intégralement respecté : la période d'essai ne peut être prolongée pour permettre l'exécution de ce délai. Le salarié a droit, sauf faute grave, à l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1221-25 du Code du travail ;
2. La rupture intervient après l'expiration de la période d'essai : l'employeur ne peut plus se prévaloir de la liberté de rupture propre à l'essai ; la rupture relève alors du régime du licenciement

D'autres clauses ont pour effet d'empêcher la rupture du contrat de travail. C'est le cas de la **clause de dédit-formation** : en contrepartie d'une formation financée par l'employeur, le salarié s'engage à rester fidèle à l'employeur pendant une certaine durée.La clause de garantie d'emploi engage l'employeur à maintenir l'emploi du salarié pendant une durée déterminée, dans les limites prévues par la clause et les règles applicables. Sa violation peut ouvrir droit à des dommages-intérêts, dont l'évaluation dépend notamment de la rédaction de la garantie et du préjudice réparable. Il ne faut pas présenter le versement de tous les salaires jusqu'au terme

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

comme une sanction automatique et universelle. . La clause de dédit-formation doit notamment porter sur des frais de formation réellement supportés par l'employeur au-delà de ses obligations légales ou conventionnelles, et prévoir une indemnité proportionnée aux frais engagés, sans priver le salarié de sa faculté de démissionner.

Plusieurs types de clauses peuvent porter sur l'exécution du contrat de travail.

- **La clause d'exclusivité** est celle par laquelle le salarié s'engage à exercer sa prestation de travail au profit d'un seul employeur. La Cour de cassation considère que la clause d'exclusivité porte atteinte à la liberté du travail ; elle n'est valable que si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
- **La clause de résidence** oblige le salarié à établir son domicile proche de son lieu de travail. Portant atteinte au droit au respect de la vie familiale, le juge retient rarement la validité de la clause de résidence ; là aussi, la clause est valable que si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
- **La clause d'objectifs** enferme l'engagement du salarié de respecter certains objectifs. Le défaut de réalisation des objectifs n'emporte pas automatiquement rupture de la relation contractuelle ; la clause d'objectifs se confond le plus souvent avec une clause de variation de la rémunération.
- **La clause de non-concurrence** implique l'obligation du salarié de ne pas travailler, au terme de la relation de travail, pour un employeur concurrent ou de ne pas créer une entreprise concurrente.Sa validité est soumise à quatre séries de conditions : elle ne doit pas porter atteinte à l'intérêt légitime de l'employeur ; elle ne doit pas empêcher le salarié de retrouver un emploi conforme à sa qualification ; elle doit être limitée dans le temps et dans l'espace ; elle doit comporter une contrepartie financière. . Le défaut de certaines conditions entraîne l'annulation de la clause ; l'irrégularité d'autres conditions peut conduire à la réfaction judiciaire de la clause de non- concurrence. L'employeur a la faculté de renoncer à la clause sous réserve de respecter certaines conditions. À défaut de renonciation, la clause de non-concurrence oblige le salarié. La violation de son engagement engage sa responsabilité ; elle est susceptible d'engager, aussi, la responsabilité civile délictuelle du nouvel employeur.

LE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE (CDD) : Le régime juridique est fixé aux articles L1241-1 à L1248-11 du Code du travail. Le CDD doit être conclu pour une tâche précise et temporaire ; il ne doit pas pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le législateur définit les cas de recours : ils doivent être liés à un remplacement (exemple du salarié absent), à un accroissement temporaire d'activité, à des emplois par nature temporaire (contrat saisonnier ou contrat d'usage) ou à une politique de formation ou d'emploi (contrats aidés). Le recours est interdit dans certains cas.

Le CDD doit être établi par écrit et comporter notamment la définition précise de son motif. Il doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche (articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du Code du travail). L'absence d'écrit ou de définition précise du motif expose à la requalification en CDI. En revanche, la seule transmission tardive du CDD ne suffit pas à entraîner cette requalification : elle ouvre droit à une indemnité plafonnée à un mois de salaire (article L. 1245-1).

. La durée maximale du CDD, ses possibilités de renouvellement et les règles de succession des contrats dépendent notamment du motif de recours et des dispositions conventionnelles applicables. À défaut de stipulation conventionnelle autorisée, le Code du travail fixe les règles supplétives correspondantes. En principe, la conclusion de CDD successifs sur un même poste suppose le respect d'un délai de carence, sauf exceptions légales, notamment pour certains contrats de remplacement, saisonniers ou d'usage. Il faut distinguer la succession de contrats sur un même poste de la succession de contrats avec un même salarié

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

. Le CDD prend normalement fin à l'échéance de son terme ou, pour un contrat à terme imprécis, lors de la réalisation de son objet. Lorsque la relation ne se poursuit pas en CDI, une indemnité de fin de contrat, en principe égale à 10 % de la rémunération totale brute, est due sauf exceptions légales, notamment dans certaines hypothèses de contrats saisonniers ou d'usage (articles L. 1243-8 à L. 1243-10). Si la relation de travail se poursuit après l'échéance du terme, elle devient en principe un CDI (article L. 1243-11). Hors période d'essai, le CDD ne peut être rompu avant son terme que dans les cas prévus par la loi : accord des parties, faute grave, force majeure, inaptitude constatée par le médecin du travail, ou rupture à l'initiative du salarié justifiant de la conclusion d'un CDI, sous réserve du préavis applicable (articles L. 1243-1 et L. 1243-2). . Le non- respect du terme oblige l'auteur fautif de la rupture à indemniser : en fonction du préjudice subi si le salarié est l'auteur ; des dommages et intérêts représentant au moins les salaires dus jusqu'au terme si l'employeur a l'initiative de la rupture.

Le non-respect de la réglementation du CDD conduit le plus souvent à la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée. Si le juge fait droit à la demande de requalification, le salarié peut prétendre à une indemnité de requalification ; une procédure directe devant le bureau de jugement est organisée.

PARTIE II : L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Depuis l'arrêt fondateur LE BERRE Soc. 10 juillet 1996, la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation distingue :

- **La modification d'un élément du contrat de travail requiert l'accord du salarié.** Il en va notamment ainsi d'une modification de la rémunération contractuelle, de la qualification, de la durée contractuelle du travail ou d'un changement de lieu de travail hors du même secteur géographique, en l'absence de clause de mobilité valable. À l'inverse, un simple changement des conditions de travail relève, en principe, du pouvoir de direction de l'employeur. .
- **Le changement des conditions de travail** : l'employeur peut imposer au salarié le changement de ses conditions de travail. Il s'agira par exemple de ses horaires de travail.

Le salarié peut s'opposer à la modification du contrat de travail. Des règles de forme particulière sont envisagées lorsque la modification repose sur un motif économique. Lorsque l'employeur propose une modification d'un élément essentiel du contrat pour un motif économique, il la notifie par lettre recommandée avec avis de réception. Le salarié dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus, délai ramené à quinze jours si l'entreprise est en redressement ou liquidation judiciaire. À défaut de réponse dans le délai applicable, il est réputé avoir accepté la modification (article L. 1222-6 du Code du travail) . Par ailleurs, depuis l'arrêt Hôtel Le Berry, la Cour de cassation considère que le salarié peut s'opposer à une modification du contrat, même si elle résulte d'une sanction disciplinaire ; l'employeur conserve le droit de prendre une autre sanction au lieu et place de la première.

L'employeur peut imposer au salarié un changement des conditions de travail dans le cadre de son pouvoir de direction. Le refus constitue un acte d'insubordination ; il ne caractérise pas nécessairement une faute grave.

LA DUREE DU TRAVAIL : Le temps de travail effectif est celui pendant lequel est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le législateur fixe certaines durées : durée maximale quotidienne en principe de 10 heures ; durée maximale hebdomadaire de 48 heures sur une même semaine, avec, en principe, une moyenne ne dépassant pas 44 heures sur douze

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

semaines consécutives, sous réserve des dérogations légalement prévues ; durée légale (35 heures) au-delà de laquelle les heures effectuées sont qualifiées d'heures supplémentaires donnant lieu à des majorations de salaires, à des contreparties obligatoires en repos ou à des repos compensateurs de remplacement. Certaines dispositions législatives sur le temps de travail sont supplétives et peuvent donc faire l'objet d'aménagements conventionnels, par exemple.

Le repos quotidien est en principe d'au moins onze heures consécutives. Le repos hebdomadaire est d'au moins vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos quotidien, soit en principe trente-cinq heures consécutives (articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du Code du travail). Le salarié acquiert en principe 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, selon les règles légales d'assimilation de certaines absences à du travail effectif. .

Le dispositif légal est susceptible d'aménagements conventionnels. La loi du 20 août 2008 a modifié le régime des forfaits. Le forfait est : soit en heures sur la semaine ou sur le mois ; soit annuel en heures, soit annuel en jours. Le législateur fixe des conditions intéressant notamment le public ou la durée des repos.

LA REMUNERATION relève en principe de la volonté des parties. Elle est néanmoins encadrée par le législateur, les partenaires sociaux ou le juge. La rémunération doit respecter le SMIC ainsi que, lorsqu'il est applicable, le minimum conventionnel correspondant à la classification du salarié. L'employeur doit respecter le minimum le plus élevé des deux. . Le montant de la rémunération est également soumis à l'exigence du principe d'égalité : applicable à raison du sexe, l'égalité doit être observée aussi au profit de n'importe quel salarié pour un travail réalisé équivalent.

Le salaire est un revenu d'un type particulier : il est considéré par le législateur comme une créance alimentaire et appelle, à ce titre, une protection opposable aux créanciers du salarié (saisie, cession ou compensation) et à ceux de l'employeur (protection du salaire en cas d'insolvabilité de l'employeur.

S'AGISSANT DU LIEU DE TRAVAIL, le régime de la modification dépend de l'existence d'une clause de mobilité et de la modification du secteur géographique. La difficulté réside dans le fait que la notion de secteur géographique n'est pas définie par la loi ou la jurisprudence. Il ressort de la jurisprudence que les éléments pris en compte pour définir le secteur géographique sont les suivants : le bassin d'emploi ou d'agglomération urbaine et la desserte en moyens de transport public.

L'appartenance de deux lieux de travail à un même secteur géographique s'apprécie objectivement, au regard notamment de leur distance, du bassin d'emploi et des possibilités de transport. Aucun de ces indices n'est, à lui seul, décisif. Si la mutation intervient dans le même secteur géographique, elle constitue en principe un changement des conditions de travail ; hors de ce secteur, elle constitue en principe une modification du contrat, sauf application d'une clause de mobilité valable. .

La clause de mobilité est celle par laquelle le salarié accepte par avance une modification de son lieu de travail ultérieur, à la demande de l'employeur. Pour être valable, la clause de mobilité doit répondre à trois conditions cumulatives :

- -La zone géographique d'application doit être définie précisément et ne doit pas conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée (Soc. 7 juin 2006). Il est à noter que cette condition est interprétée largement par la Cour de cassation puisque celle-ci considère que la clause imposant une sphère de mobilité « dans la limite géographique du territoire français » est suffisamment précise (Soc. 9 juillet 2014).
- -Elle doit être stipulée dans l'intérêt de l'entreprise.
- -Elle doit avoir été expressément acceptée par le salarié.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

- La clause de mobilité doit être prévue par le contrat de travail soit lors de sa conclusion, soit pendant l'exécution du contrat, mais dans ce dernier cas elle nécessitera un accord exprès du salarié et la rédaction d'un avenant au contrat.

Dès lors que la clause est valable, l'employeur pourra unilatéralement modifier le lieu de travail du salarié, sans que l'accord de ce dernier soit nécessaire.
Ce principe est tout de même assorti d'exceptions. En effet, la clause de mobilité ne peut faire l'objet d'une mise en œuvre abusive par l'employeur (Soc. 2 mars 2005). Cela suppose :

- Que la clause soit justifiée au regard de l'intérêt de l'entreprise (Soc. 3 mai 2012 : n'est pas justifiée, la clause mise en œuvre en raison des problèmes relationnels du salarié avec les autres).
- Que l'employeur respecte un délai de prévenance. Le délai de prévenance n'est pas fixé par la loi ou par la jurisprudence, il dépend de la situation (pour exemple : un délai de prévenance de quatre jours alors que le salarié concerné a un enfant en bas âge est insuffisant (Soc. 19 mars 2003).
- Que la mise en œuvre de la clause ne porte pas atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale (Soc. 14 octobre 2008).

La bonne foi de l'employeur dans la mise en œuvre de la clause est présumée, c'est donc au salarié de rapporter la preuve contraire (Soc. 23 février 2005).

Enfin, précisons que la clause de mobilité ne peut pas prévoir un changement d'employeur, celle-ci serait nulle dans un tel cas (Soc. 23 septembre 2009).

À NOTER : si le changement des conditions de travail peut être imposé au salarié, il en va autrement pour les salariés protégés. En effet, même en cas de changement des conditions de travail, l'employeur devra recueillir l'accord du salarié dès lors que celui-ci a le statut de salarié protégé (représentant du personnel par exemple).

LES POUVOIRS DE L'EMPLOYEUR : L'autorité de l'employeur se traduit par l'existence de pouvoirs que l'employeur détient dans l'entreprise à l'égard des salariés.

1.LE POUVOIR RÉGLEMENTAIRE : c'est avant tout le pouvoir détenu par l'employeur d'édicter des normes, d'élaborer unilatéralement un règlement qui s'imposera à l'ensemble des salariés.L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins 50 salariés. Cette obligation s'applique au terme d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil est atteint (article L. 1311-2 du Code du travail) ; :

- **Les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement** ; ces mesures prévoient également les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la sécurité et de la santé des salariés dès lors qu'elles apparaissent compromises.
- L**es règles générales et permanentes relatives à la discipline et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur.**
- **Les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés**,
- **Le règlement intérieur rappelle les dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel, aux agissements sexistes, ainsi que l'existence du dispositif de protection des lanceurs d'alerte** (article L. 1321-2 du Code du travail).
- Le contenu doit être conforme aux dispositions légales et conventionnelles ; il ne peut être discriminatoire.
- L'élaboration du règlement intérieur doit suivre 4 étapes :

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

- **La rédaction du règlement** (en langue française, accompagné le cas échéant de traductions en langues étrangères) relève du pouvoir de l'employeur.
- **La consultation des représentants du personnel**. Le règlement intérieur ne peut être introduit (ou modifié) qu'après avoir été soumis à l'avis du comité social et économique (CSE) (C. trav., art. L. 1321-4). Attention, toutefois car la Cour de cassation a rappelé le 19 janvier 2022 que la consultation n'est pas nécessaire quand les modifications font suite à une injonction de l'inspection du travail (Cass. Soc. 19 janvier 2022, n° 20- 12196).
- **La communication du règlement intérieur à l'inspecteur du travail** : le règlement intérieur, accompagné de l'avis du CSE doit être communiqué à l'inspecteur du travail. Cette disposition s'applique également en cas de modification du règlement intérieur ou de retrait de clauses de celui- ci.
- L**a publicité du règlement intérieur** : le règlement intérieur doit être déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes du ressort de l'entreprise ou de l'établissement (C. trav., art. R. 1321-2).Le règlement intérieur doit être porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l'embauche (article R. 1321-1 du Code du travail). Il doit également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes compétent (article R. 1321-2). Son opposabilité suppose le respect des formalités applicables ; l'affichage n'est plus le seul mode de publicité admis. (Cass. soc. 1er juillet 2020, n° 18-24556).

2.AU TITRE DE SON POUVOIR DE CONTROLE, l'employeur peut mettre en œuvre des dispositifs de surveillance justifiés et proportionnés, sous réserve du respect des règles d'information des salariés, de consultation du CSE lorsqu'elle est requise et de protection des données personnelles. Ce pouvoir ne lui confère pas un droit général d'accès à l'ensemble des données personnelles des salarié. . Plusieurs obligations d'information pèsent en effet sur l'employeur qui souhaite mettre en place un procédé de surveillance des salariés. Préalablement à sa mise en place, l'employeur doit informer et consulter le CSE (art. L. 2312-38) ;

Les salariés doivent être individuellement informés : (article L1222-4 Code du Travail).
Le système de surveillance doit avoir pour but de préserver un intérêt légitime de l'entreprise pouvant être caractérisé par un risque particulier de vol ou par la surveillance d'un poste de travail dangereux (fondement : article L1121-1/Atteinte aux libertés des salariés).

La mise en place d'un système de géolocalisation des salariés est licite si elle répond à quatre conditions cumulatives dont trois sont les mêmes que pour la vidéosurveillance :
La géolocalisation doit être justifiée par l'intérêt légitime de l'entreprise et ne doit pas porter une atteinte disproportionnée à la vie privée des salariés ;
Le CSE doit être préalablement consulté (article L2312-38 du Code du travail) ;
Les salariés doivent être individuellement informés (article L1222-4 du Code du travail) ;
On relèvera que l'obligation de déclaration préalable à la CNIL n'existe plus depuis l'entrée en vigueur du Règlement général relatif à la protection des données le 25 mai 2018.
Par ailleurs, selon la jurisprudence (Soc. 3 novembre 2011, n°10-18.036), l'utilisation d'un système de géolocalisation pour contrôler la durée du travail d'un salarié n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail s'il est possible de recourir à un autre moyen pour contrôler la durée du travail.

3.LE POUVOIR DISCIPLINAIRE est un autre attribut des pouvoirs reconnus à l'employeur : celui de sanctionner le salarié coupable d'une faute dans l'entreprise. L'article L1331-1 du Code du travail définit la sanction : « *constitue une sanction, toute mesure autre que des observations verbales prises par l'employeur à la suite d'un agissement considéré par l'employeur comme fautif, que cette sanction soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération* ».

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

La sanction disciplinaire découle donc de l'appréciation de l'employeur des faits fautifs. En d'autres termes, l'employeur peut considérer un fait comme étant fautif. Il convient de distinguer trois types de fautes :

- La faute simple est un comportement fautif qui peut justifier une sanction disciplinaire, y compris un licenciement pour cause réelle et sérieuse, sans rendre nécessairement impossible le maintien du salarié pendant le préavis. Elle n'entraîne pas, par elle-même, la perte des indemnités de licenciement et de préavis .
- **La faute grave** : celle qui empêche la poursuite du contrat de travail et rend impossible le maintien du salarié pendant la période de préavis (Soc. 26 février 1991). Rappelons que la faute grave fait perdre au salarié le bénéfice de l'indemnité de licenciement ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis.
- **La faute lourde :** manquement assorti d'une intention de nuire. La faute lourde fait aussi perdre au salarié le bénéfice de l'indemnité de licenciement ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis.

A noter : La faute disciplinaire doit être distinguée de l'incompétence ou de l'insuffisance professionnelle.

Les sanctions classiques sont les suivantes :

- L'avertissement : sanction mineure, la procédure disciplinaire est donc simplifiée puisqu'elle nécessite uniquement un écrit informant le salarié des griefs retenus et lui notifiant l'avertissement.
- Le blâme est une sanction disciplinaire. Comme pour l'avertissement, la nécessité d'un entretien préalable dépend notamment de la question de savoir si la sanction est susceptible d'avoir une incidence sur la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, ainsi que des dispositions conventionnelles applicables. La seule inscription au dossier ne doit pas être présentée comme le critère légal général. .
- La mise à pied disciplinaire : elle entraîne la suspension du contrat de travail du salarié, le privant ainsi de son salaire durant cette durée. La mise à pied disciplinaire ayant des conséquences graves, elle doit être limitée dans le temps. Le règlement intérieur doit préciser la durée maximale de la mise à pied (Soc. 7 janvier 2015).
- La mutation et la rétrogradation disciplinaires : lorsqu'elles emportent une modification du contrat de travail, elles ne peuvent être imposées au salarié sans son accord. En cas de refus, l'employeur peut envisager une autre sanction, dans le respect des règles disciplinaires.
- Le licenciement
- Le licenciement pour faute grave

Le Conseil de prud'hommes vérifie si la sanction est régulière, objective et proportionnée.
Les juges ont également la possibilité d'annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée (article L1333-2 du Code du travail) à condition que la sanction ne soit pas un licenciement.

Certaines sanctions sont interdites :

1. Les sanctions discriminatoires (article 1132-1 du Code du travail) ;
2. Les sanctions pécuniaires qui sont interdites par l'article L. 1331-2 du Code du travail. La suppression d'une prime en raison d'un comportement considéré comme fautif peut constituer une sanction pécuniaire prohibée ; elle doit être distinguée de la non-attribution d'une prime dont les conditions objectives ne sont pas remplies. ;
3. Les sanctions non prévues par le règlement intérieur (Soc. 26 juin 2010) ;
4. Les sanctions faisant suite à l'exercice d'un droit : droit de retrait ou droit de grève par exemple.

Avant toute procédure disciplinaire, il faut s'assurer du respect de deux règles.

- **La prescription** : L'article L1332-4 du Code du travail précise « *aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où*

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ».

L'employeur dispose de deux mois à compter du jour où il a eu connaissance des faits fautifs pour engager les poursuites disciplinaires. Il ne s'agit donc ni d'un délai courant nécessairement à compter de la commission des faits, ni d'un délai dans lequel la sanction définitive doit obligatoirement être prononcée. Lorsque la procédure comporte un entretien préalable, l'envoi de la convocation permet d'engager les poursuites dans ce délai. (Article L. 1332-4 du Code du travail) . Il est à préciser que ce délai de prescription est interrompu par :

- La convocation à l'entretien préalable (date d'envoi de la convocation) ;
- Les poursuites pénales : L'article L. 1332-4 prévoit une exception à la prescription disciplinaire lorsque les mêmes faits ont donné lieu à l'exercice de poursuites pénales dans les deux mois suivant le jour où l'employeur en a eu connaissance. Il faut donc vérifier l'identité des faits et la date d'engagement des poursuites pénales. .

Ce délai commence à courir au jour où l'employeur a eu connaissance du fait fautif.

- **Un fait fautif ne peut faire l'objet que d'une seule sanction** : Selon la règle « Non bis in idem », l'employeur ne peut prononcer une nouvelle sanction pour un fait qu'il a déjà sanctionné.

Toute sanction doit être motivée et notifiée par écrit au salarié. En revanche, l'entretien préalable prévu à l'article L. 1332-2 du Code du travail n'est pas requis lorsque la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Lorsque l'entretien est requis, son omission constitue une irrégularité susceptible d'entraîner l'annulation de la sanction, sous réserve du régime particulier du licenciement disciplinaire.

L'employeur doit tout d'abord convoquer le salarié à un entretien préalable. La convocation doit préciser la date, l'heure, le lieu de l'entretien, la possibilité pour le salarié de se faire assister : mais seulement par une personne appartenant au personnel de l'entreprise (contrairement au licenciement), l'objet de l'entretien : l'employeur doit indiquer qu'une sanction disciplinaire est envisagée.

L'employeur est tenu d'entendre le salarié lors d'un entretien préalable.
Si le salarié ne vient pas, l'employeur peut reporter l'entretien si le salarié a un motif légitime ou si le salarié en fait une demande. Il s'agit d'une faculté pour l'employeur.

La notification de la sanction : La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables suivant l'entretien préalable, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. La sanction doit être notifiée et motivée.

Remarque : La mise à pied conservatoire doit être distinguée de la mise à pied disciplinaire. En effet, tandis que la mise à pied disciplinaire est une sanction disciplinaire, la mise à pied conservatoire est une solution provisoire avant le prononcé d'un licenciement.
La mise à pied conservatoire est une mesure provisoire, et non une sanction disciplinaire, qui écarte immédiatement le salarié de l'entreprise lorsque les faits reprochés rendent cette mesure indispensable, dans l'attente de la décision disciplinaire définitive. Elle ne préjuge pas nécessairement d'un licenciement. L'employeur doit respecter la procédure disciplinaire applicable (article L. 1332-3 du Code du travail).

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

PARTIE III : L'EXTINCTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

LES MODES DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A L'INITIATIVE DU SALARIE :

- **La démission est l'acte par lequel le salarié rompt de façon unilatérale et non motivée son contrat de travail**. Les dispositions relatives à la démission se trouvent aux articles L1237-1 à L1237-3 du Code du travail. La démission n'est, en principe, soumise à aucun formalisme légal particulier : elle peut être écrite ou verbale, sous réserve des dispositions conventionnelles applicables. Elle doit résulter d'une volonté claire et non équivoque du salarié de rompre son CDI. Depuis la loi du 21 décembre 2022, un régime distinct de présomption de démission existe en cas d'abandon volontaire de poste : l'employeur doit mettre le salarié en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Cette présomption peut être contestée devant le conseil de prud'hommes. Elle ne signifie pas que toute absence injustifiée vaut automatiquement démission (articles L. 1237-1-1 et R. 1237-13 du Code du travail). .

Si le salarié est libre de démissionner quand il le souhaite, il doit cependant respecter un préavis. L'article L1237-1 du Code du travail précise que la durée du préavis est fixée soit par des dispositions légales, soit par des dispositions conventionnelles (convention ou accord collectif), soit par les usages.
De plus, le contrat de travail peut prévoir une durée de préavis en cas de démission, mais cette durée ne pourra pas être moins favorable (donc plus longue) que celle prévue par la convention collective applicable, et ce, même si celle-ci l'y autorise (Soc. 1er juillet 2008).

En principe, la démission n'ouvre pas immédiatement droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). Des exceptions existent toutefois, notamment pour certaines démissions considérées comme légitimes, pour les salariés démissionnant afin de poursuivre un projet de reconversion professionnelle réel et sérieux dans les conditions prévues par les textes, ou à l'issue d'un réexamen de leur situation par France Travail après une période de chômage. .

- **La prise d'acte est un mode de rupture unilatérale du contrat par lequel le salarié met un terme à son contrat en raison de griefs qu'il reproche à son employeur** (Soc., 25 juin 2003, n° 01-42679). Il saisira ensuite le Conseil de prud'hommes afin de faire requalifier cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La prise d'acte est une notion d'origine jurisprudentielle. Aucune forme n'est imposée, il suffit que le salarié indique clairement que sa décision fait suite au comportement de l'employeur. La prise d'acte peut ainsi être présentée par l'avocat du salarié (Soc. 4 avril 2007, n° 05-42847). La seule exigence est qu'elle soit directement adressée à l'employeur.

La prise d'acte entraîne la rupture immédiate du contrat de travail. Le juge apprécie ensuite si les manquements imputés à l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat. Si tel est le cas, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou d'un licenciement nul lorsqu'un motif de nullité est caractérisé. Dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission.

La loi du 1er juillet 2014 prévoit une procédure prud'homale spécifique en cas de prise d'acte. La phase de conciliation est supprimée et l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui doit statuer dans le délai d'un mois (article L1451-1 du Code du travail). Ainsi, la prise d'acte ne constitue ni un licenciement ni une démission, mais une rupture produisant les effets de l'un ou de l'autre. Dès lors que les griefs sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail (Soc. 26 mars 2014, n° 12-23634), la prise d'acte produit les effets :

- D'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc. 25 juin 2003, n° 01-42679) ;

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

- D'un licenciement nul le cas échéant si elle émane d'un salarié protégé (Soc. 17 novembre 2011, n° 10-16353) ; si elle est fondée sur la discrimination dont le salarié a fait l'objet (Soc. 12 décembre 2012, n° 10-28166) ; lorsqu'elle fait suite au harcèlement moral subi par un salarié (Soc. 29 février 2013, n° 11-26560).

Les juges vérifieront : La réalité des faits reprochés et la gravité des faits invoqués, ceux-ci devant rendre impossible la poursuite de la relation de travail.

- **Le départ à la retraite est un mode de rupture du contrat à l'initiative du salarié**. Il s'agit d'un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Le salarié doit avoir atteint l'âge lui permettant d'obtenir la liquidation de sa pension de retraite. Il doit en informer son employeur. Un préavis doit être respecté. Le salarié a le droit à une indemnité de départ à la retraite.

LES MODES DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A L'INITIATIVE DE L'EMPLOYEUR

Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur par le biais d'un licenciement, lequel peut être fondé sur deux types de motifs :

- le motif économique : motif non inhérent à la personne du salarié
- le motif personnel : il s'agit d'un motif de licenciement inhérent à la personne du salarié qui se décompose soit en motif disciplinaire (le licenciement est alors fondé sur une faute sérieuse, une faute grave ou une faute lourde ; un tel motif oblige l'employeur à respecter la procédure disciplinaire) soit en motif non-disciplinaire (notamment les conséquences de la maladie du salarié, l'insuffisance professionnelle ou l'insuffisance de résultats peuvent constituer des motifs personnels non-disciplinaires de licenciement. Sur ce dernier point, il convient de préciser que le licenciement pour motif personnel non disciplinaire peut notamment reposer sur une insuffisance professionnelle ou, sous certaines conditions, une insuffisance de résultats. L'état de santé du salarié ne peut pas, en lui-même, justifier un licenciement. En revanche, des absences prolongées ou répétées peuvent justifier un licenciement lorsqu'elles perturbent le fonctionnement de l'entreprise et rendent nécessaire le remplacement définitif du salarié. Il faut distinguer cette hypothèse du licenciement pour inaptitude, qui obéit à un régime spécifique

L'employeur qui envisage le licenciement doit respecter une procédure.

1.La convocation à un entretien préalable, il doit convoquer le salarié à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la convocation (article L. 1232-2 du Code du travail). Le délai ne se calcule donc pas à partir de la seule date d'envoi de la lettre. . L'article R1232-1 du Code du travail fixe les mentions obligatoires que doit contenir la convocation :

- L'objet du litige, c'est-à-dire le projet de licenciement. Cependant, l'employeur n'a pas à préciser les griefs retenus (Soc. 6 avril 2016, n° 14-23198).
- Le jour, l'heure et le lieu de l'entretien.
- L'information expresse du salarié de son droit de se faire assister soit par une personne de l'entreprise soit, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, par un conseiller extérieur choisi sur une liste dressée dans chaque préfecture. Le défaut de cette mention est sanctionné par le versement au salarié d'une indemnité au plus égale à un mois de salaire.

En revanche, la convocation n'a pas à indiquer les griefs allégués contre le salarié.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

. En cas de licenciement disciplinaire, les poursuites doivent être engagées dans les deux mois suivant le jour où l'employeur a eu connaissance des faits fautifs, sous réserve de l'exception relative aux poursuites pénales (article L. 1332-4 du Code du travail).

2.L'entretien préalable : Si l'entretien préalable est obligatoire pour l'employeur, le salarié n'est pas tenu de s'y rendre. Si le salarié demande le report de l'entretien, l'employeur n'est pas tenu de faire droit à sa demande (Soc. 25 novembre 1992, n° 89-42186). Par ailleurs, l'employeur peut se faire représenter par une personne appartenant à l'entreprise lors de cet entretien.

L'entretien doit permettre à l'employeur d'indiquer les motifs du licenciement envisagé et au salarié de se défendre.

À NOTER : l'absence ou l'irrégularité de la convocation ou de l'entretien ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

3.La lettre de licenciement : Si l'employeur décide de licencier le salarié, il doit alors lui envoyer une lettre de licenciement devant contenir certaines mentions obligatoires. La lettre, le cas échéant précisée par l'employeur, fixe les limites du litige.
E n matière de licenciement pour motif personnel, la lettre de licenciement est expédiée par lettre recommandée avec avis de réception, au moins deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable. Elle énonce le ou les motifs du licenciement (article L. 1232-6 du Code du travail). Lorsque le licenciement est disciplinaire, s'ajoute le délai maximal prévu par l'article L. 1332-2 : la sanction doit être notifiée au plus tard un mois après le jour fixé pour l'entretien
.

Classiquement, la lettre de licenciement fixe les limites du litige : ainsi, en cas de contestation devant le Conseil de prud'hommes, seuls les motifs invoqués dans la lettre de licenciement pourront être invoqués par l'employeur au soutien de sa décision (Soc. 20 mars 1990).

La lettre de licenciement doit énoncer les motifs de la rupture. Depuis les ordonnances de 2017, il faut distinguer l'absence de motif, l'insuffisance de motivation et l'absence de cause réelle et sérieuse. Une motivation insuffisante ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse lorsque le salarié n'a pas demandé de précisions ; elle ouvre alors droit à une indemnité ne pouvant excéder un mois de salaire. La lettre, éventuellement précisée dans les conditions légales, fixe les limites du litige (article L. 1235-2 du Code du travail).
.
La lettre de licenciement doit contenir des éléments précis et matériellement vérifiables.
Il est à préciser qu'en cas de licenciement économique, la lettre doit mentionner la cause économique invoquée, mais également les conséquences sur l'emploi.

La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement (art. L. 1235-2 al. 2).
L'employeur pourra préciser, après la notification du licenciement, la lettre de licenciement,

- Soit à son initiative ;
- Soit à la demande du salarié.

Pour un licenciement pour motif personnel, le salarié peut demander des précisions dans les quinze jours suivant la notification du licenciement. L'employeur dispose de quinze jours après réception de cette demande pour répondre s'il le souhaite. Il peut également préciser les motifs de sa propre initiative dans les quinze jours suivant

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

la notification (article R. 1232-13 du Code du travail). En effet, cette précision permet de compléter les motifs énoncés, non de substituer après coup un motif entièrement nouveau.

L'employeur peut dorénavant « préciser » les motifs de licenciement ultérieurement à sa notification, soit à son initiative, soit à la demande du salarié selon des modalités fixées par le décret n° 2017-1702 du 15 décembre 2017 relatif à la procédure de précision des motifs énoncés dans la lettre de licenciement.

Désormais, le juge devra prendre en compte, pour l'appréciation des motifs de licenciement, la lettre de licenciement, mais aussi la précision patronale éventuelle.

Les sanctions d'une insuffisante motivation de la lettre de licenciement dépendent de l'initiative du salarié.
-Si le salarié forme auprès de l'employeur une demande de précision de la lettre de licenciement, et que la lettre reste toujours imprécise, alors le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (la jurisprudence antérieure s'applique toujours, et en particulier : Soc. 29 novembre 1990 « Rogié », l'imprécision des motifs équivaut à une absence de motif).

-En revanche, selon l'article L. 1235-2 al. 3 et 4 : *« À défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire ».*

Lorsque le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, une irrégularité de procédure peut ouvrir droit à une indemnité ne pouvant excéder un mois de salaire (article L. 1235-2 du Code du travail). L'insuffisance de motivation de la lettre obéit au régime spécifique exposé ci-dessus ; elle ne doit pas être automatiquement assimilée à une absence de cause réelle et sérieuse. .

En cas de licenciement pour motif personnel, la cause de la rupture du contrat de travail doit être inhérente à la personne du salarié. Le licenciement doit reposer sur une cause :

- Réelle : le licenciement doit reposer sur des faits objectifs, existants et exacts ; la cause doit donc reposer sur des éléments matériellement vérifiables ; et
- Sérieuse : La cause doit être sérieuse, c'est-à-dire présenter une importance suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail. Elle n'implique pas nécessairement une faute, ni l'impossibilité de maintenir le salarié pendant le préavis, qui caractérise la faute grave. .

Le motif de licenciement ne repose pas forcément sur une faute, il peut s'agit de l'incompétence du salarié (insuffisance professionnelle), ou encore d'un trouble objectif affectant le bon fonctionnement de l'entreprise.

L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité du salarié à exercer correctement ses fonctions. Le licenciement pour insuffisance professionnelle ne repose pas sur une faute du salarié, mais sur son incompétence (Soc. 25 janvier 2006, n° 04-40.310).

L'insuffisance de résultat désigne la non-réalisation par le salarié des objectifs fixés.

Il existe un cas particulier de licenciement : le licenciement pour inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail. Il s'agit du cas où le salarié est déclaré inapte à son emploi. La procédure se décompose alors en trois étapes : le constat d'inaptitude, l'obligation de reclassement, le licenciement du salarié.

L'employeur peut procéder aux licenciements économiques de salariés non traité dans ce fascicule.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

Le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. La cause réelle doit exister et doit être exacte. Elle est aussi objective. Cette exigence conduit à interdire le licenciement fondé sur une mésentente ou sur une perte de confiance. Si cette dernière ne peut justifier le licenciement, en revanche les éléments objectifs qui la motivent doivent être contrôlés par le juge.
La cause sérieuse est celle présentant une certaine gravité et rendant impossible, sans dommage pour l'entreprise, la continuation du travail ; le licenciement est nécessaire.
Le défaut de cause réelle et sérieuse donne lieu, au profit du salarié, à des dommages et intérêts ; le montant dépend de l'effectif de l'entreprise et de l'ancienneté du salarié.
Le licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être distingué du licenciement nul. En cas de nullité, le salarié peut, selon le motif de nullité et les règles applicables, demander sa réintégration. Lorsqu'il ne demande pas sa réintégration ou que celle-ci est impossible, il peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire, dans les cas relevant de l'article L. 1235-3-1 du Code du travail, sans préjudice des autres sommes dues. .

. Le salarié peut, sous réserve des conditions applicables, prétendre à une indemnité de licenciement, sauf notamment en cas de faute grave ou lourde, ainsi qu'à une indemnité compensatrice de congés payés pour les droits acquis et non pris, y compris en cas de faute lourde.

L'employeur doit délivrer un certificat de travail et une attestation chômage. . L'employeur établit un solde de tout compte faisant l'inventaire des sommes versées lors de la rupture. Le salarié n'est pas tenu de signer le reçu. S'il le signe, il peut le dénoncer dans les six mois suivant sa signature ; passé ce délai, le reçu devient libératoire pour l'employeur uniquement pour les sommes qui y sont mentionnées (article L. 1234-20 du Code du travail).

La mise à la retraite : Lorsque le salarié atteint l'âge de la retraite, l'employeur peut prononcer la rupture du contrat de travail sans avoir à justifier d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Cependant, l'âge de la retraite n'entraîne pas rupture automatique du contrat de travail. La loi du 17 décembre 2008 impose plusieurs conditions. . Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture constitue un licenciement, dont la validité s'apprécie selon les règles applicables, notamment celles prohibant les discriminations fondées sur l'âge.

La mise à la retraite est possible pour les salariés ayant atteint l'âge de 67 ans et jusqu'à l'âge de 70 ans Entre 67 et 69 ans, l'employeur peut proposer une mise à la retraite, mais il ne peut pas l'imposer au salarié. Il doit l'interroger par écrit trois mois avant son anniversaire ; le salarié dispose d'un mois pour répondre. En cas de refus ou de non-respect de la procédure, l'employeur ne peut pas le mettre à la retraite pendant l'année qui suit. Cette procédure se renouvelle chaque année jusqu'au 69e anniversaire. À partir de 70 ans, l'employeur peut en principe procéder à une mise à la retraite d'office, sous réserve du préavis et des autres règles applicables
Après 70 ans, l'employeur peut, d'office, mettre à la retraite le salarié. Il devra respecter un préavis d'une durée d'un mois si le salarié a une ancienneté dans l'entreprise comprise entre 6 mois et 2 ans ; 2 mois si le salarié a une ancienneté supérieure à 2 ans.
La mise à la retraite donne droit à une indemnité au moins égale à l'indemnité légale de licenciement.

LES AUTRES MODES DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL : La législation a prévu d'autres modes de ruptures du contrat de travail telles que la force majeure, la résiliation judiciaire ou encore la rupture conventionnelle. Il est également possible à l'employeur et au salarié de conclure une transaction, non pas pour rompre le contrat de travail, mais pour régler les conflits intervenus à l'occasion de cette rupture. Celle-ci présente l'autorité de la chose jugée lorsqu'elle comprend, notamment, des concessions réciproques.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

La rupture conventionnelle a été introduite par la loi de modernisation du 25 juin 2008. Le régime juridique de la rupture conventionnelle est exposé aux articles L1237-11 à L1237-16 du Code du travail. Elle peut se définir comme le mode de rupture amiable du contrat qui résulte d'une convention conclue par les parties et qui doit garantir la liberté de consentement. Cette rupture ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
La rupture conventionnelle n'est possible que dans le cadre d'un CDI. Ce type de rupture ne présente un intérêt que lorsque le contrat de travail à durée indéterminée est devenu définitif (après la période d'essai). La rupture conventionnelle suppose la mise en œuvre d'une procédure spécifique.

L'article L1237-12 du Code du travail prévoit que les parties conviennent d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens. La loi n'impose pas de forme particulière pour la convocation à l'entretien de rupture conventionnelle ni de délai minimal entre cette convocation et l'entretien. Les parties doivent toutefois respecter les règles relatives à leur assistance prévues par l'article L. 1237-12 du Code du travail. Le salarié peut se faire assister dans les conditions légales ; l'employeur ne peut être assisté que si le salarié l'est lui-même. Le respect de ces garanties participe à la liberté du consentement.

Le Code du travail prévoit seulement les modalités de l'assistance. Lors du ou des entretiens de rupture conventionnelle, le salarié peut se faire assister :

- par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un représentant du personnel, d'un salarié titulaire d'un mandat syndical ou de tout autre salarié ;
- en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste établie par l'autorité administrative.

Le conseiller extérieur n'est donc pas une troisième possibilité ouverte dans tous les cas (article L. 1237-12 du Code du travail)

.

Si le salarié décide de se faire assister, il doit en informer l'employeur qui peut alors également se faire assister. L'article précité précise les personnes susceptibles d'assister l'employeur : une personne de son choix appartenant à l'entreprise ou si l'entreprise comporte moins de 50 salariés, une personne appartenant à une organisation syndicale patronale, ou par un employeur relevant de sa branche.

En revanche les parties ne peuvent pas se faire assister par un avocat.

Enfin le Code n'impose aucun délai minimum entre l'entretien et la signature de l'accord. La convention peut être signée le lendemain de l'entretien, voire le jour même de l'entretien.

. Aux termes de l'article L. 1237-13 du Code du travail, la rupture conventionnelle est formalisée par une convention signée par les deux parties. Celle-ci définit notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture, qui ne peut être inférieur à l'indemnité légale de licenciement, ainsi que la date de rupture, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. Selon cet article, la convention doit comporter au moins les deux mentions suivantes : préciser le montant de l'indemnité spécifique de rupture qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du Code du travail ; préciser la date de la rupture du contrat de travail qui ne peut être fixée avant le lendemain de l'homologation par l'administration.
A compter de la date de signature de la convention par l'employeur et le salarié, l'un et l'autre dispose d'un délai de 15 jours calendaires (tous les jours de la semaine sont comptabilisés -voir précisions ci-dessous-) pour exercer ce droit de rétractation. À l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente (employeur – ou tiers mandaté, par exemple l'expert-comptable de l'employeur – ou salarié) adresse une demande d'homologation à

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

l'autorité administrative compétente (DRETS), avec un exemplaire de la convention de rupture. Depuis le 1er avril 2022, et sauf lorsqu'il s'agit d'un salarié protégé cette demande d'homologation doit obligatoirement être effectuée à partir du site « Télé RC »

Le droit de rétractation s'exerce par une lettre adressée par tout moyen permettant d'attester de sa date de réception par l'autre partie (article L. 1237-13 du Code du travail).

L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de 15 jours ouvrables (c'est à dire que sont exclus les dimanches et les jours fériés), à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect de la liberté de consentement des parties et des conditions prévues par le Code du travail : respect des règles relatives à l'assistance des parties, au droit de rétractation, au montant minimal de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;

A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise (il s'agira donc d'une homologation « tacite » ou « implicite ») et l'autorité administrative est dessaisie.

La validité de la rupture conventionnelle de droit commun est subordonnée à son homologation. La signature de la convention ne rompt donc pas immédiatement le contrat de travail : elle fait notamment courir le délai de rétractation. En l'absence de demande d'homologation ou en cas de refus d'homologation, la rupture conventionnelle ne peut pas produire son effet extinctif et le contrat de travail se poursuit (article L. 1237-14 du Code du travail). :

- si l'homologation est refusée par l'autorité administrative dans le délai de 15 jours ouvrables mentionné ci-dessus dans ce cas, l'une ou l'autre des parties (ou les deux) peut former un recours contre ce refus d'homologation (voir ci-dessous) ;
- si l'autorité administrative n'est saisie par aucune des parties de la demande d'homologation de la convention.

Pour les salariés protégés, la rupture conventionnelle relève d'un régime particulier : elle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, et non à l'homologation de droit commun. Dans ce cas, la rupture du contrat ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'autorisation (article L. 1237-15 du Code du travail)

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

THÈME II : LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL

PARTIE I : LA REPRÉSENTATION SYNDICALE

La liberté syndicale, inscrite dans le bloc de constitutionnalité et soutenue par des textes internationaux, implique à la fois une liberté collective (celle de créer ou de cesser l'activité d'un syndicat) comme celle d'adhérer ou non à un syndicat. Elle se traduit, notamment, par une interdiction de toute discrimination en raison de l'adhésion à un syndicat ou de l'activité syndicale.

Certains droits sont accordés à tous les syndicats. C'est le cas de la possibilité d'agir en justice ou de constituer une section syndicale. Cependant, le législateur a entendu réserver certaines prérogatives aux syndicats dits « représentatifs », c'est-à-dire les syndicats qui ont le plus d'influence. La prérogative la plus importante réservée aux syndicats représentatifs est celle de conclure des accords collectifs à travers leurs délégués syndicaux qu'ils sont seuls à pouvoir désigner.

Aujourd'hui, les cinq syndicats représentatifs au niveau national et interprofessionnel sont : la CGT, la CFTC, la CFDT, la CFE-CGC et la CGT-FO.

Il convient de préciser en premier lieu le cadre de la représentativité. En effet, il est important de comprendre que tous les syndicats n'ont pas le même cadre d'intervention et ne seront pas représentatifs au même niveau. En effet, un syndicat peut exercer ses prérogatives et être représentatif à différents niveaux : Au niveau de l'établissement ; Au niveau de l'entreprise ;
Au niveau national ; Au niveau interprofessionnel.

La représentativité syndicale a été rénovée par la loi du 20 août 2008. La loi a supprimé la présomption irréfragable de représentativité et a modifié les critères de représentativité. Ces derniers sont désormais au nombre de sept : le respect des valeurs républicaines, l'indépendance, la transparence financière, l'ancienneté, l'audience, l'influence et les effectifs (et cotisations).

L'audience minimale exigée au niveau interprofessionnel et de la branche est de 8 % ; elle est de 10 % au niveau de l'entreprise.

Prérogatives réservées aux syndicats représentatifs	La désignation d'un représentant de la section syndicale (RSS) est ouverte, sous les conditions légales, aux syndicats non représentatifs ayant constitué une section syndicale. Le RSS représente le syndicat dans l'entreprise, mais ne dispose pas, en principe, du pouvoir de négocier et de conclure les accords collectifs.
Prérogatives partagées avec des syndicats non- représentatifs	convocation à la négociation du protocole préélectoral, présentation des candidats au premier tour des élections, constitution d'une section syndicale
Prérogatives réservées aux syndicats non-représentatifs	- nomination d'un représentant de la section syndicale

Il est primordial de distinguer deux types de délégués dans l'entreprise :

- **Les délégués qui représentent le personnel (délégation du personnel au CSE), qui sont élus par les salariés ;**
- **Les délégués qui représentent le syndicat, ceux-ci sont désignés par le syndicat (délégué syndical et représentant de section syndicale).**

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

Aux termes de l'article L2143-3 du Code du travail, un délégué syndical peut être désigné sous réserve que l'entreprise et le syndicat remplissent plusieurs conditions :

- L'entreprise ou l'établissement doit compter au moins de 50 salariés ;
- Une section syndicale doit avoir été constituée au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
- Pour être délégué syndical, la personne doit : Être titulaire d'un contrat de travail et travailler dans l'entreprise depuis au moins un an (article L2143-1 du Code du travail) ;
- Être âgée de 18 ans révolus (article L2143-1 du Code du travail).
- Dans les entreprises ou établissements d'au moins 50 salariés, une organisation syndicale représentative ayant constitué une section syndicale peut désigner un délégué syndical lorsque ce seuil d'effectif a été atteint pendant douze mois consécutifs. Le délégué syndical est, en principe, choisi parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés à titre personnel et dans leur collège au premier tour des dernières élections du CSE, quel que soit le nombre de votants. L'article L. 2143-3 du Code du travail prévoit toutefois des possibilités de désignation subsidiaires, notamment lorsqu'aucun candidat ne remplit les conditions ou lorsque les élus concernés renoncent par écrit à leur droit d'être désignés
- . .

L'article L2143-3 du Code du travail indique que le délégué syndical représente le syndicat. Celui-ci a une mission principale : il négocie et conclut les accords collectifs au nom du syndicat. Il anime également la section syndicale. Le délégué syndical dispose d'un crédit d'heures pour accomplir sa mission (article L2143-13 du Code du travail).

. Le mandat du délégué syndical prend notamment fin lors du renouvellement des institutions représentatives du personnel, ce qui impose, le cas échéant, une nouvelle désignation au regard des résultats des élections. Il peut également prendre fin par révocation par le syndicat, renonciation du salarié ou cessation des conditions permettant l'exercice du mandat.

Le législateur a prévu la possibilité pour les syndicats de désigner un représentant de la section syndicale sous réserve que soient respectées trois conditions :

- Le syndicat doit avoir constitué une section syndicale dans l'entreprise ;
- Dans les entreprises ou établissements d'au moins 50 salariés, un syndicat non représentatif ayant constitué une section syndicale peut désigner un RSS. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, un syndicat non représentatif ayant constitué une section peut, dans les conditions légales, désigner un membre de la délégation du personnel au CSE comme RSS (articles L. 2142-1-1 et L. 2142-1-4 du Code du travail). ;
- Le syndicat ne doit pas être représentatif
- Le législateur a entendu permettre aux syndicats non représentatifs d'avoir un représentant dans l'entreprise malgré leur impossibilité de désigner un délégué syndical.

PARTIE II : LES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

L'obligation de mettre en place les institutions représentatives du personnel (CSE ou représentants syndicaux) dépend de l'effectif de l'entreprise dont le calcul répond à des règles précises. Dès lors que celles-ci doivent être mises en place, elles pourront l'être à plusieurs niveaux.

Les élections professionnelles permettent aux salariés des entreprises concernées d'élire leurs représentants du personnel au sein du CSE. Déterminantes, les élections du CSE obéissent à des règles précises définies par le Code du travail et doivent donc se dérouler selon certaines étapes.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

. Le CSE doit être mis en place dans les entreprises d'au moins 11 salariés, lorsque cet effectif est atteint pendant douze mois consécutifs (article L. 2311-2 du Code du travail). Il a remplacé les anciennes institutions représentatives du personnel au terme de la période de transition achevée le 1er janvier 2020. Elles permettent aux salariés d'élire la délégation du personnel qui constituera cette unique instance représentative du personnel : le CSE, qui a fusionné et remplacé les anciennes instances (Comité d'entreprise, Délégué du personnel et Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail).

Le rôle et les missions du CSE marquent une véritable révolution des instances représentatives du personnel en France. Dans les entreprises employant entre 11 et 49 salariés, les missions du CSE se rapprochent de celles attribuées aux anciens DP. Dans ces entreprises, les missions du CSE recouvrent :

- L'expression individuelle et collective des salariés sur les salaires, l'application du droit du travail et des conventions et accords collectifs
- La promotion de la santé, la sécurité et des bonnes conditions de travail, en lien avec les formations obligatoires à ce sujet
- La possibilité de réaliser des enquêtes concernant les accidents du travail ou les maladies professionnelles
- La capacité à saisir l'inspection du travail
- Le droit d'alerte

. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le CSE exerce des attributions élargies, notamment en matière d'information et de consultation sur les décisions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise. L'accès à ces attributions obéit aux règles légales de franchissement du seuil, qui tiennent notamment compte de son atteinte pendant douze mois consécutifs (articles L. 2312-1 et L. 2312-2 du Code du travail).

Les missions du CSE comprennent aussi, l'information/consultation sur

- L'organisation générale de l'entreprise
- Les orientations stratégiques
- La situation économique et financière
- La politique sociale et relative aux conditions de l'emploi
- Tous les évènements ou situations susceptibles d'affecter les conditions d'emploi des salariés (contrôle de l'activité, plan de restructuration ou de licenciement, OPA ou procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation)
- La participation au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de l'entreprise

Enfin le CSE, sur l'aspect des activités sociales et culturelles, a pour mission le bien-être des salariés et la négociation d'avantages pour les employés (ticket restaurant, billetterie, promotions sur des sorties, chèques cadeaux, etc.). L'attribution d'avantages sociaux et culturels aux salariés de l'entreprise est loin d'être la seule mission du CSE.

Cette instance unique devra s'occuper de l'ensemble des sujets de l'entreprise, véritable pivot du dialogue social au sein de l'entreprise.

La loi du 14 juin 2013 a imposé la constitution de la base de données économiques et sociales, la BDES, base de données informatique regroupant toutes les informations transmises de façon récurrente au CSE.
La loi Climat du 22 août 2021 l'a rebaptisée Base de données économiques, sociales et environnementales : BDESE.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

L'objectif est de faciliter l'exploitation, la compréhension et la mise en perspective des données par les représentants du personnel. Le support de la base de données peut être informatique ou papier.
Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.

. La mise à disposition actualisée des informations récurrentes dans la BDESE vaut communication des rapports et informations au CSE dans les conditions et limites prévues par les textes. La seule existence de la base ne dispense donc pas l'employeur de respecter ses autres obligations d'information et de consultation (article L. 2312-18 du Code du travail).

Pour l'exercice de leurs missions, les représentants du personnel peuvent se déplacer librement dans l'entreprise, nonobstant les limites apportées aux déplacements d'autres salariés.
Le crédit d'heures, également appelé « heures de délégation », est le nombre d'heures auquel les représentants ont droit pour l'exercice de leur mandat, durant leur temps de travail. Il s'agit de permettre aux représentants de jouir d'heures de liberté pour exercer leur mandat, sans qu'ils n'en pâtissent dans leur rémunération. Ces temps sont de plein droit considérés comme du temps de travail et payés à l'échéance normale.

Parmi les moyens offerts aux représentants du personnel pour exercer leurs missions, figure l'obligation faite à l'employeur de fournir un local. L'employeur est tenu de mettre à la disposition de la délégation du personnel du CSE un local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission, et, notamment, de se réunir. La fourniture de ce local est obligatoire, quel que soit le nombre des délégués et la taille de l'entreprise ou de l'établissement. Cette obligation est impérative et d'ordre public : ainsi, se rend coupable du délit d'entrave à l'exercice des fonctions membres élus du CSE, l'employeur qui ne fournit le local qu'avec plusieurs mois de retard parce qu'il n'avait pas eu la possibilité de disposer d'un local plus tôt, ces difficultés ne constituant pas un cas de force majeure.

Amenés (éventuellement) à entrer en conflit avec l'employeur, les représentants du personnel disposent d'un statut protecteur. Celui-ci se traduit surtout par la mise en œuvre d'une procédure spéciale de licenciement, impliquant une autorisation délivrée par l'inspecteur du travail à l'issue d'un contrôle approfondi. Le contentieux est principalement de nature administrative.

LA GREVE : Le droit de grève est un droit fondamental reconnu aux salariés. Ce droit a été déclaré de valeur constitutionnelle par l'alinéa 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Le droit de grève est également reconnu au niveau international.
La Cour de cassation définit la grève comme « une cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles » (Soc. 18 janvier 1995 ; Soc. 13 novembre 1996). Par conséquent, pour être qualifié de grève, le mouvement doit réunir 3 conditions cumulatives :

- Il doit y avoir un arrêt total du travail
- Le mouvement doit être collectif et concerté
- Le mouvement doit avoir pour but d'appuyer des revendications professionnelles

. Lorsque les conditions de la grève ne sont pas réunies, le mouvement ne bénéficie pas de la qualification juridique de grève, ni de la protection spécifique qui s'y attache. Il faut toutefois distinguer cette hypothèse de l'exercice abusif du droit de grève : un mouvement peut constituer une grève tout en donnant lieu, à l'occasion de son déroulement, à des comportements fautifs individuellement imputables à certains participants.
La grève doit aussi être régulière. . La grève entraîne normalement une perturbation de l'activité : celle-ci ne suffit pas à caractériser un abus. Il faut distinguer la désorganisation de la production, conséquence possible d'une grève, de la désorganisation de l'entreprise elle-même, susceptible de caractériser un abus dans les conditions retenues par la jurisprudence. De même, une occupation des locaux ou un piquet de grève ne rend

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

pas automatiquement la grève illicite ; en revanche, des actes tels que des violences, des dégradations ou des entraves à la liberté du travail peuvent donner lieu à des conséquences juridiques propres.
La grève emporte en principe suspension du contrat de travail. Le salarié gréviste ne peut être licencié sauf faute lourde ; à défaut d'une telle faute, le licenciement est nul et le salarié peut réclamer sa réintégration.

La suspension du contrat entraîne la suspension de la rémunération. L'employeur ne peut remplacer par CDD ou contrat de travail temporaire un salarié absent pour raison de grève.

. La participation à une grève licite ne constitue pas, en elle-même, une faute. En revanche, des actes fautifs personnellement imputables à un gréviste, commis à l'occasion du mouvement, peuvent engager sa responsabilité dans les conditions propres à la responsabilité civile ou pénale. Sur le plan du contrat de travail, l'exercice du droit de grève ne peut justifier un licenciement sauf faute lourde imputable au salarié ; à défaut, le licenciement est nul (article L. 2511-1 du Code du travail)

Afin de mettre un terme à la grève, salariés et employeur peuvent décider de signer un accord de fin de conflit. Selon les formes adoptées, celui-ci est soit un accord collectif de travail, soit un engagement unilatéral.

La grève peut cesser par le jeu d'une conciliation, d'une médiation ou d'un arbitrage. Prévues par le Code du travail, ces procédures sont en réalité peu employées en pratique.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite